

0003094-18.2017.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... corroboram a existência do tráfico.

Cabe observar que é lícito o ingresso em domicílio mediante autorização do morador ou, mesmo sem mandado judicial, se houver fundados indícios da existência de flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição e art. 240 do CPP). Como o tráfico, na modalidade de guardar ou ter em depósito drogas, é crime permanente, sua consumação se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifácio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003094-18.2017.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003094-18.2017.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 323/2017 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio, 1607/2017 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Averiguado

Leonardo Lima da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

LEONARDO LIMA SILVA (fls. 9) foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (fls. 55/56).

Isso porque, segundo consta, em 13 de setembro de 2017, no período noturno, na Rua Sete de Julho cruzamento com a Rua Pedro de Toledo, Centro, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, o acusado trazia consigo e guardava, para entrega a consumo, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: Josivaldo Gomes de Amorim (fls. 18), PM Wellinton Jeisson Bruno Guilherme (fls. 10/11) e Diego Monzani dos Santos (PM Inativo) (fls. 12/13).

O acusado foi notificado (fl. 137) e apresentou defesa prévia (fls. 143/146), por defensor nomeado (fls. 139), negando a prática do delito e pedindo absolvição, sem arrolar testemunhas.

Recebida a denúncia (fls. 150/152), foi realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de

prova.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 9/13; 18), auto de apreensão e entrega (fls. 7/8), relatório (fls. 48/50) e laudos periciais (fls. 20/22; 32/34).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Os Policiais Militares efetuavam patrulhamento de rotina na via pública supracitada, quando avistaram o denunciado de pé na esquina conversando com um outro indivíduo não identificado que estava em uma motocicleta preta, momento em que Leonardo entregou ao indivíduo da motocicleta um objeto e recebeu deste algo de cor amarela.

Os policiais militares aproximaram-se, no entanto o condutor da motocicleta fugiu em alta velocidade.

Ato contínuo, em revista pessoal ao denunciado foram encontradas uma cédula de vinte reais, que estava em suas mãos, uma porção de maconha embalada e a quantia de R\$ 17,00 (dezesete reais) em seu bolso. Em seguida, os policiais militares conduziram-no até a sua residência onde encontraram dentro do guarda roupas do denunciado um saco plástico contendo uma porção de maconha e sete porções de maconha embaladas, além de uma faca utilizada para separação da droga.

As substâncias apreendidas foram periciadas. Laudo de Constatação n.º 420.422/2017 (fls. 18/20) apontou resultado positivo para a porção de 47.05 (quarenta e sete gramas e cinco miligramas) de Tetrahydrocannabinol. O laudo pericial da faca foi juntado às fls. 28/30 e restou positivo para vestígios de substância denominada Tetra-hidrocanabinol.

Foram apreendidos: uma faca de cozinha; a quantia de R\$37,00 em dinheiro e 47,8 gramas de maconha acondicionadas em 9 porções, sendo que uma estava na posse do averiguado e 8 foram localizadas em sua residência, no interior do guarda roupas em seu quarto.

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para:

1- tetrahydrocannabinol – THC, nas amostras colhidas de nove invólucros plásticos do tipo filme, retorcido, encerrando porção de fragmentos vegetais, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com massa líquida de 45,05 grama(s).

2- tetrahydrocannabinol – THC nas amostras colhidas de vestígios de substância entorpecente encontrados na faca de cozinha da marca Simonaggio. A perícia na faca também constatou que ela é eficaz para a realização de corte e atestou ser comum o uso de facas de cozinha no fracionamento e comercialização de drogas.

A testemunha Josivaldo Gomes de Amorim, ex-sogro do acusado, relatou que acompanhou a busca dos policiais que encontraram a droga. Sabe que o acusado e sua filha usavam drogas. Desconhece sobre tráfico.

A testemunha PM Wellinton Jeisson Bruno Guilherme narrou que durante patrulhamento avistaram uma motocicleta parada e um a pé; ao notarem a viatura, saiu em alta velocidade enquanto o outro ficou em pé, que era o acusado. Viu ser entregue um objeto de cor amarelada, que era R\$ 20,00, e com ele foi encontrada uma porção de entorpecente. Na casa do acusado foram encontradas porções de maconha no quarto dele, apontado pelo sogro. O acusado falou que o motociclista tinha drogas para vender. No dia dos fatos, por dúvida, foi instaurado inquérito. Já havia feito abordagens do acusado na praça onde se situava o fórum antigo, não sendo localizada droga, apenas dinheiro.

A testemunha PM inativo Diego Monzani dos Santos confirmou o relato da denúncia, afirmando que já tinha abordado o acusado na praça do antigo fórum.

Em seu interrogatório, o acusado negou a acusação, afirmando que estava com R\$ 20,00 no bolso e subindo para a praça para comprar lanche, quando o motoqueiro parou para perguntar quem estava vendendo drogas e respondeu que não sabia, mas logo após foi abordado. Afirmou que a droga era para seu uso.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Em patrulhamento, acusado foi visto na esquina entre a Av. Pedro de Toledo e Rua 07 de Julho, entregando um objeto para um indivíduo em uma moto, que por sua vez lhe entregou um objeto de cor amarelada. Ao avistar a viatura, o indivíduo da moto se evadiu e o acusado foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, os policiais localizaram na mão do réu uma nota de R\$20,00 e, em seu bolso, foi encontrada uma porção de maconha embalada em um plástico e a quantia de R\$17,00.

Questionado se possuía mais drogas, o acusado admitiu que guardava entorpecentes em sua casa, para onde os policiais diligenciaram. Autorizado o ingresso pelo sogro do acusado, os policiais localizaram no imóvel, no guarda roupas do quarto do réu, um saco plástico contendo uma porção maior e mais sete porções menores de maconha embaladas, além de uma faca utilizada para separação da droga.

Frise-se que o acusado já tinha sido abordado antes, na praça onde se situava o prédio antigo do fórum, mas sem drogas, só com dinheiro e, na data dos fatos, confirmou ter sido abordado por uma pessoa que pretendia comprar drogas. Essa pessoa se evadiu e, segundo os policiais, deixou com o acusado a nota de R\$ 20,00 apreendida, o que leva a crer que o acusado comercializou drogas. Diante disso a versão do acusado de que estava ali apenas para comprar lanche e por acaso foi abordado por um usuário é inverossímil.

Pela quantidade e modo de acondicionamento das drogas, bem como pelos locais onde foram encontradas, não é possível afirmar de plano que elas se destinavam a consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06). Além disso, a apreensão de petrechos e quantia em dinheiro, corroboram a existência do tráfico.

Cabe observar que é lícito o ingresso em domicílio mediante autorização do morador ou, mesmo sem mandado judicial, se houver fundados indícios da existência de flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição e art. 240 do CPP). Como o tráfico, na modalidade de guardar ou ter em depósito drogas, é crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, de modo que o agente se encontrará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 303 do CPC).

No caso, o acusado foi visto em ato característicos de venda de droga e trazendo consigo entorpecentes e valores, o que caracterizou situação de flagrante a legitimar a busca domiciliar. Ademais, o acusado não relatou ter sido coagido para falar onde as drogas se encontravam, nem há indícios mínimos de que ela sofreria represália, por ele imaginada, caso se mantivesse em silêncio. Diante disso, não houve ilicitude ou abuso apto a acarretar a ilicitude das provas obtidas:

1. Durante a realização de diligência verificar a existência de indícios de crime após o recebimento de notícia anônima circunstanciada, a guarnição policial se deslocou até o local dos fatos. O agravante, por sua vez, ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, no que foi seguido pelos policiais até que adentrou à residência. Diante da fundada suspeita da prática de crime, os milicianos adentraram à residência e lograram apreender significativa quantidade de entorpecente.

2. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida" (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/8/2018). (AgRg no HC 556.588/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

III - A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes.

IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os

milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280). Habeas corpus não conhecido. (HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Vale dizer ainda que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas pretendessem incriminar o acusado falsamente, mesmo porque os policiais não o conheciam de abordagens anteriores.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexiste presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais ou que não é possível presumir a culpa apenas porque a droga foi encontrada dentro do imóvel. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelo acusado precisaria ser verossímil e não foi. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém desconhecido queria prejudicá-lo, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Ademais, o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 se caracteriza como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali mencionadas, dentre elas a de ter drogas em depósito, sem autorização, como descrito na denúncia.

Logo, a conduta não está acobertada por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática do delito.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, vale lembrar que "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a

atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.
 2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.
 3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.
 4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.
 5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.
 6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.
 7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.
 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)
- PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.
 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da

pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituesa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenação transitada em julgado para a Defesa em 23/11/2020 (data do fato: 08/11/2017) (fls. 186/188).

Conforme o entendimento jurisprudencial, as condenações por fatos posteriores ao descrito na denúncia não caracterizam antecedentes e condenações antigas podem ser valoradas negativamente porque os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 anos aplicável à reincidência (art. 64, I, do CP)

A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção

de não culpa. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (HC 443.678/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (HC 433.543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Assim, a condenação mencionada deve ser desprezada, motivo pelo qual o acusado deve ser considerado primário.

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, considerando que o acusado é nascido em 02/07/1999 (art. 65, I, do CP), que, contudo, não repercute na dosimetria, uma vez que a pena se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Consequentemente a pena não se altera.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de diminuição de 1/6 a 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o acusado é primário e inexistem indicativos de seu envolvimento em organização criminosa ou atividades criminosas, não bastando a quantidade de droga isoladamente para afastar o redutor: "Esta Corte vem decidindo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova, para atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa" (AgRg no AREsp 1636928/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Assim, inexistindo razões para maior rigor, cabe aplicar a maior fração de diminuição, ou seja, 2/3, o que resulta em: 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa.

Logo, torno definitiva a pena em: 1 ano e 8 meses e pagamento de 166 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pelo montante (inferior a 4 anos), a pena deve ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).

O acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a pena não supera 4 anos, ele é primário e não cometeu o

crime com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 44 do CP).

Na condenação superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP).

Considerando que a sanção penal deve cumprir função pedagógica e social, cabível a aplicação de duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução (arts. 43, I e IV; 45 e 46 do CP; e art. 483-A das NSCGJ).

Fica prejudicada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar LEONARDO LIMA SILVA à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, à entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Como efeito da condenação, imponho a perda dos bens e valores apreendidos (arts. 5º, LIV, e 243, parágrafo único, da Constituição e art. 91 do CP). Os bens poderão ser destinados à conservação e utilização, se houver interesse público, ou à alienação, enquanto o produto da arrematação e valores apreendidos deverão ser mantidos em depósito até o trânsito em julgado (arts. 61 a 63 da Lei 11.343/06). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico. Serve a presente como ofício.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

O acusado responde ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar. Portanto, ele faz jus ao direito de recorrer em liberdade, salvo se por outros motivos deva ficar preso (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Saem os presentes intimados.

José Bonifácio, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA